

1502292-78.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502292-78.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502292-78.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2275710/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 20727712 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3396/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 3396/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2275710 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DE MATOS SOUSA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

DANILO DE MATOS SOUSA, RIAN CELSO DA SILVA FERREIRA, RAFAEL FEITOSA FERREIRA e ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA foram denunciados por incursão nos incisos II e V do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Narra a inicial que no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 22h20min, nas proximidades da Rua Recife, 16, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, os acusados previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas Vanilda Neves Nogueira, Ademilton Rodrigues Nogueira e Davi Neves Nogueira, de nove anos de idade, em seus poderes, restringido suas liberdades, subtraíram, para proveito comum, três celulares da marca Motorola (preto, vermelho e azul), cartões de crédito e a quantia de R\$ 3.200,00, além do veículo Fiat Toro, de placa PYN8B97 São Paulo/SP, pertencentes às vítimas.

Recebida a denúncia, os réus Danilo, Rian e Rafael foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, os réus Danilo, Rian e Rafael foram interrogados. Foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu Rogério (fls.305-6).

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto as Defesas requerem, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da menoridade relativa e confissão do réu Rian, afastamento das causas de aumento pela restrição de liberdade e uso de arma de fogo, bem como a fixação de regime penitenciário inicial brando e aplicação da detração penal. É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12-8), auto de exibição e apreensão (fls. 19-20 e 96), auto de reconhecimento de pessoa (fls.27-8, 89), auto de reconhecimento de objeto (fl. 97), além de prova oral colhida. A autoria é certa.

O réu Danilo, em solo policial (fl. 10), disse que: (sic) "foi chamado por um colega para realizar um saque em um caixa eletrônico, bem como dirigir uma Fiat Toro e aceitou participar pelo valor de R\$100 (cem reais), porém quando estava na Rua Adutora do Rio Claro, nº 680, Nova Mauá/SP, resolveu desistir de transportar o carro, ao saber que os demais meliantes estavam mantendo uma família em restrição de liberdade, momento em que foi abordado pela Guarda Municipal".

Em juízo, negou os fatos. Disse que foi preso pelos policiais porque tem antecedentes criminais e apanhou na Delegacia após dizer que não assinaria os papéis. Conhece os corréus de vista, porque moram no mesmo bairro, e não sabe dizer se participaram do roubo (mídia digital).

O réu Rian, na fase administrativa (fl.11), disse que: (sic) "cientificado de suas prerrogativas legais, inclusive de permanecer em silêncio, este confessa a prática criminosa, dizendo que saiu com o carro Palio Weekend juntamente com 'DANILO', 'RAFAEL FEITOSA' e 'BICUDO' para a prática de um roubo, todos com sua função, e abordaram a FIAT TORO, sendo que neste momento estava na direção do veículo Palio. Que momentos após, enquanto estava estacionado, aguardando os demais comparsas retornarem com o veículo Fiat Toro, não tendo nada mais a declarar".

Em juízo, negou os fatos. Disse que estava em casa dormindo quando foi preso pelo policial Sérgio. Negou ter confessado a prática do roubo e delatado a participação dos corréus. Disse que foi ameaçado pelo policial Sérgio em abordagem anterior (mídia digital).

O acusado Rafael, em solo policial (fls.102-4), negou os fatos. Disse que não conhece os corréus e no dia dos fatos saiu de sua casa por volta das dez e pouco da noite. Foi para um samba, com o amigo Guilherme de Jesus. No caminho encontraram Jenifer e Jessica, que não conhecia, e foram todos juntos. Por volta das duas da manhã, foram embora e foi para a casa do amigo Guilherme, onde dormiu.

Em juízo, negou os fatos. Disse que na data dos fatos foi em um samba com um amigo e duas meninas que conheceram no local e dormiu na casa do amigo. Afirmou que conhecia a vítima, que ajudava a descarregar as mercadorias. Disse que a blusa encontrada não era sua, que não pegaram na sua casa. Disse que foi o acusado Rian quem liberou as vítimas e sabe disso porque leu tudo (mídia digital).

As versões contraditórias dos réus não merecem credibilidade, diante dos depoimentos seguros e firmes das vítimas, dos policiais e guardas municipais.

A vítima Ademilton, na fase antejudiciária (fl.08) disse que: (sic) " na data de ontem por volta das 22h20min, ao sair do seu comércio localizado na Rua Recife nº 16, Jardim Oratório, Mauá/SP, juntamente com sua esposa Vanilda Neves Nogueira, e seu filho Davi Neves Nogueira, de 09 (nove) anos, no seu veículo Fiat Toro, observou que estava sendo perseguido por um automóvel, Fiat Palio Weekend, branco, PLACAS KWK 4900, e dentro dele 04 (quatro) indivíduos anunciaram assalto, mediante arma de fogo, e ato contínuo 03 (três) desses entraram no veículo e levaram o declarante com sua família para uma rua sem saída, afirmando que: 'passa R\$120.000,00 (cento e vinte mil) reais, senão vamos entrar na sua casa', ocasião em que a vítima entregou seus pertences, dentre eles três celulares da marca motorola (preto, vermelho e azul), cartões de crédito e a quantia de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Neste momento, 03 (três) desses indivíduos saíram com o veículo da vítima dizendo que iriam sacar dinheiro com os cartões, e um ficou na posse da sua família juntamente com o declarante, dentro do veículo dos assaltantes, tendo inclusive sido amarrado com um 'enforca gato'. Logo depois, um dos indivíduos que saíram com seu carro retornou de moto afirmando: 'a casa caiu, a guarda municipal deu um 'enquadro', pegou um parceiro e outro fugiu, vamos aguardar a decisão se vamos liberá-los ou não'. Logo em seguida, o meliante que mantinha o declarante e sua família em restrição de liberdade, liberou todos nas proximidades do seu comércio, tendo o declarante solicitado socorro a transeuntes. Neste ato, comparece nesta Delegacia para prestar declarações e reconhece Danilo de Matos Sousa e Rian Celso da Silva Ferreira como sendo autores do roubo. Igualmente, as vítimas foram orientadas quanto a necessidade de vislumbrarem eventuais saques ou transferências indevidas que tenham sido realizadas pelos agentes criminosos com os cartões de crédito subtraídos".

No mesmo sentido o depoimento da vítima Vanilda (fl.09).

Em juízo, a vítima Vanilda afirmou que junto com seu filho e marido foram abordados pelos roubadores por volta das 22h, levados a um cativado e ficaram presos dentro do carro deles com um dos indivíduos. Os outros pegaram o número de cartão e dinheiro e saíram com seu veículo Fiat/Toro. Ficaram presos até por volta das 03h da manhã. O indivíduo que ficou, disse que estavam demorando muito e depois do outro rapaz dizer que "a casa caiu", foi embora, abandonando o local. Disse que foram abordados por dois indivíduos, tinha mais um que ficou junto no veículo e acredita que tinha um quarto indivíduo, que passava informações. Afirmou ter visto arma de fogo. Reconheceu os réus Danilo e Rian na Delegacia. Disse que os réus estavam encapuzados, mas pôde fazer o reconhecimento. O acusado Danilo ficou bastante tempo com as vítimas, tinha a pele negra e estava com um moletom preto. Disse que conversou bastante com o réu Rian, que estava com um moletom preto também, ele é baixo, meio fortinho, cabelo baixo. Ficou bastante tempo com o réu Rian e pôde ver o seu cabelo quando ele tirou a touca. Disse que ficou presa no veículo Palio e informou os dados da placa do carro na Delegacia porque seu filho anotou. Em juízo, reconheceu os acusados Danilo e Rian (mídia digital).

Sob o contraditório, a vítima Ademilton reiterou a sua versão. Disse que havia quatro indivíduos no veículo Pálio e desceram três dizendo "você perdeu" "pode descer do carro". Foi jogado no banco de trás, em cima de seu filho, que machucou o braço. Disseram que era um sequestro e queriam a quantia de R\$120.000,00. Foram levados para um cativeiro e ficaram presos dentro do carro deles, foi amarrado e saíram com o seu veículo. Levaram dinheiro, cartões e celular. Um dos indivíduos era muito agressivo. Afirmou que foram abordados por volta das 22h20min e libertados por volta das 03h30min da manhã. Disse que reconheceu "Bicudo" e Rafael na Delegacia. Afirmou que já conhecia o acusado Rafael, que frequentava seu estabelecimento, e pôde reconhecê-lo porque quando o acusado desceu do seu carro, ele esqueceu o moletom dentro, blusa que ele sempre usava, e apesar de estar com touca ninja, com a movimentação da máscara, pôde ver o cavanhaque de cor vermelha do acusado Rafael. Disse que sua esposa viu a placa do veículo e passaram os dados para a Guarda Municipal. Afirmou que o réu Rian estava de máscara, conhecia o acusado de vista. Em juízo, reconheceu os réus Rafael e Danilo (mídia digital).

É da tradicional experiência judicante que a palavra da vítima nos crimes de roubo deve prestigiar-se, de comum, por sua isenção ordinária. Voto paradigmático do min. Soriano de Souza, no egrégio Supremo Tribunal Federal, assentara já que "todos nós, que somos juízes, sabemos disto: não se pode deixar de tomar com muita consideração as declarações da ofendida, desde que sejam verossímeis e minuciosas" (apud Espínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, ed. Rio, 1980, n. 427).

O guarda municipal Marcos, na fase administrativa (fl. 05), historiou que: (sic) "na data dos fatos faziam patrulhamento de rotina, ocasião em que, logo após serem comunicados por um transeunte acerca de um roubo de veículo, mais especificamente de uma FIAT TORO PRATA, vislumbaram o referido veículo estacionado na Rua Adutora do Rio Claro, nº 680, Nova Mauá/SP, ocasião que iniciaram a abordagem e identificaram Danilo de Matos Sousa, que apresentava comportamento suspeito ao lado do veículo. Neste sentido, cientificado quanto aos seus direitos constitucionais, o indivíduo em questão confessou a prática criminosa juntamente com outros indivíduos, porém informou que apenas teria sido contratado para dirigir o veículo FIAT TORO de um lado para outro da cidade e realizar saque de dinheiro. Desse modo conduziram o indivíduo em questão para os devidos esclarecimentos nesta delegacia".

Em juízo, disse que um popular informou a prática de roubo de um veículo Fiat/Toro, cor prata. Viram um veículo com as mesmas características, com a luz interna acesa, a porta entreaberta e com um indivíduo próximo. Feita a abordagem o indivíduo apresentou intenso nervosismo e disse que tinham roubado o veículo. Sua função era levar o veículo para determinado local e realizar saques com o cartão da vítima, e disse que os demais envolvidos estavam com as vítimas (mídia digital).

Destaca-se a ausência de qualquer irregularidade na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais. Nessa linha: "A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol de suas atribuições constitucionais (art. 144, 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. Se qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há que se falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão". (HC nº 129.932-SP, STJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).

No mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei processual penal, em momento algum, exige que policiais civis ou militares sejam acionados para que dêem suporte ou apoio a

quem esteja efetuando a prisão, como aventado na impetração. Precedentes. [...]">(STJ - RHC 45.173/SP 5ª Turma Rel. Min. Jorge Mussi j. 06.05.2014 DJe 14.05.2014).

O policial civil Sérgio, em solo policial (fl.07), disse que: (sic) "juntamente com os demais investigadores encontrou na Rua José Carlos da Silva, de nº 74, Mauá/SP o veículo Palio Weekend, branco, estacionado na calçada, com as mesmas descrições passadas pela vítima, e ao bater na porta se apresentou o Sr. Celso Geraldo Ribeiro Ferreira, genitor de 'Rian', que informou ser proprietário do referido veículo. Ato contínuo, o investigador solicitou acesso a casa para falar com seu filho, sendo de pleno deferido, e ao se aproximar do quarto, se apresentou Rian Celso da Silva Ferreira, que confessou a prática criminosa juntamente com outros três autores. Desse modo, apresentou nesta delegacia o Sr. Rian Celso da Silva Ferreira, bem como o veículo Palio Weekend, e um celular que o indivíduo portava para adoção das providências cabíveis".

Em juízo, disse que foi apurado que os acusados Danilo, Rafael, Rian e "Bicudo" tinham participado de um roubo. O réu Danilo disse que receberia R\$100,00 para fazer o "cavalo", ficar com o carro, e não conseguiu porque foi abordado pela Guarda Municipal. Durante diligências, encontraram o veículo Pálio na frente da casa do pai do acusado Rian, o réu estava na casa e confessou que tinha usado o carro do pai na prática do roubo, bem como informou a participação dos corréus Danilo, Rafael e "Bicudo". Não lembra se as vítimas disseram que os réus usavam máscara. As vítimas reconheceram os réus Danilo e Rian, com certeza. Disse que já abordou anteriormente o irmão do acusado Rian e não sabia que o réu morava na residência diligenciada (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Além disso, não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os agentes tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Joel, testemunha da Defesa e amigo do réu Danilo, em juízo, disse que ouviu dizer que os roubadores estavam encapuzados (mídia digital).

Diante da prisão em flagrante do réu Danilo com o veículo roubado, da localização do veículo utilizado no roubo que era de propriedade do pai do acusado Rian, do depoimento do policial Sérgio informando que o réu Rian disse que praticou o roubo com os corréus e utilizou o veículo do pai, do depoimento do guarda Marcos informando que o acusado Danilo afirmou ter praticado o roubo com outras pessoas, do depoimento contraditório dos réus em juízo, das declarações seguras das vítimas sobre a participação dos réus no delito, além dos reconhecimentos na fase antejudiciária e em juízo, a responsabilidade penal dos denunciados é incontroversa.

As majorantes do concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de

liberdade das vítimas -que foram cerceadas do direito constitucional de ir e vir por cerca de cinco horas- foram comprovadas pela prova oral colhida, notadamente a palavra das vítimas. Registre-se, respeitado entendimento em contrário, ser dispensável a apreensão da arma de fogo, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização. Nessa linha: STJ, HC 29.346-SP, DJU 13.10.2003. Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie" (HC 109176/SP - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 5ª Turma - j. 24/11/2008).g.n.

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosam-se as penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de uma criança de 09 anos, que machucou o braço, inclusive, fato que deve ser valorado em desfavor dos acusados, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Em caso análogo:

"Apelação. Roubo majorado. Art. 157, caput e §2º, II, do CP. Dosimetria. Aumento da pena-base que se deu com fundamento adequado (emprego de faca e presença de criança de quatro anos no veículo subtraído). Reforma da r. sentença apenas para ponderar a atenuante da confissão em favor do apelante. Majorante do concurso de agentes bem comprovada. Tese de roubo tentado afastada. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 0010205-11.2018.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020).

Na segunda etapa, majoro a reprimenda do réu Danilo em mais 1/3, diante da bi-reincidência específica (certidão fls. 59-60 - procs 9718-68.2018 e 19094-40.2012), totalizando 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Sobre a possibilidade de majoração da pena em patamar maior devido à dupla reincidência específica:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. ART. 14 DA LEI 10.826/03 (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (3) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. PATAMAR FIXADO EM 1/3. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUPLA REINCIDÊNCIA GENÉRICA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO IDÊNTICO AO DA DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA (5) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não é possível realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando se tratar de reincidência específica. 3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. No caso, em relação aos delitos de roubo circunstanciado, o acréscimo da pena pela reincidência se deu em 1/3 (um terço), aumento que não se

mostra desarrazoado, tendo em vista escorreita valoração dada diante da dupla reincidência específica do paciente. 4. A fixação de idêntico patamar de aumento de pena na valoração da dupla reincidência genérica - delitos de corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido-, e da dupla reincidência específica - referente ao delito de roubo circunstanciado-, viola o princípio da proporcionalidade, porquanto sopesa de maneira equivalente circunstâncias desiguais. In casu, o Tribunal de Justiça reduziu a fração de aumento em relação à dupla reincidência específica (delito de roubo circunstanciado) de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), mantendo idêntico acréscimo em relação aos demais delitos, nos quais reincidência do paciente se dava de forma genérica. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda imposta ao paciente para 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ, HC 333531 / RJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 20/10/2015).g.n.

"Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a dupla reincidência específica do apelante, já tendo sido antes condenado definitivamente outras duas vezes pela prática de delito idêntico, conforme se infere de fls. 95/96 (Processos nº 0000780-09.2017.8.26.0142 e 0000351-76.2016.8.26.0142), suas reprimendas foram acertadas e novamente agravadas em 1/3." (TJSP, AP nº 1500200- 94.2020.8.26.0142, Des. Rel. Marco Antônio Cogan, j. 24.02.21).g.n.

Na segunda fase, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão em relação ao réu Rian, considerando-se a tese apresentada em juízo. Diante de sua menoridade relativa, sua pena retorna ao patamar mínimo.

Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante. Nessa linha:

"Como se vê, na terceira fase da dosimetria, aplicou-se a fração mínima de 1/3 para a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, ao argumento de que ocorreu prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre os agentes, o que foi fundamental para a expropriação patrimonial, e o patamar de 2/3 para a causa de aumento oriunda do emprego de arma de fogo, por entender que o emprego de arma de fogo mostrou-se imprescindível para subjugar a vítima, notadamente porque estava na frente de sua residência e poderia ter se evadido para dentro do seu imóvel, caso não fosse ameaça com uso do artefato bélico. A utilização da arma, em via pública, eis que a vítima estava em frente a sua residência na hora dos fatos, gerou ainda mais riscos, tudo nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador aplicar cumulativamente as majorantes em concurso. Nesse mesmo sentido, é assente a jurisprudência deste STJ e também do STF, segundo a qual, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais." (STJ, HC 577363, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 28/05/2020 - grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sob as

outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. 3. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, Julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019).

"Na derradeira etapa, pela majorante do concurso de agentes, a pena foi exasperada à razão de 1/3, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa. E, em razão da majorante do emprego de arma de fogo, a pena foi aumentada à razão de 2/3 perfazendo 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 23 dias multa, no mínimo legal. Conforme mencionado acima, o cálculo da pena está correto, uma vez que as duas majorantes ora analisadas não se encontram mais previstas no mesmo parágrafo com a mesma fração de aumento, de modo que devem ser valoradas separadamente, por pura escolha do legislador com a referida alteração legislativa." (Apelação nº 1501168-40.2019.8.26.0537, Relatora Des. Ely Amioka, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 02/06/2020, Data de publicação: 02/06/2020 - grifo nosso).

"Na fase derradeira da dosimetria, incidiu, primeiro, o aumento mínimo (de um terço) pela majorante da comparsaria e, depois, o aumento de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Não obstante o pleito da esforçada defesa, a incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo, o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, o qual estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrário sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos. Nesse sentido, recente julgado desta Col. Corte de Justiça Estadual: Apelação nº 0047853-25.2018.8.26.0050, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1526276-77.2019.8.26.0050 - Voto nº 49783 8 Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, Julg. em 01/04/2019." (APELAÇÃO CRIMINAL nº 1526276-77.2019.8.26.0050, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 19/05/2020, Data de publicação: 19/05/2020).

"Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei nº 13.654/18: (a) num primeiro momento, elevou a reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157, par. 2º, II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157, par. 2º-A, do Código Penal), chegando a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa. O procedimento não merece censura, porquanto de acordo com o novo modelo legal, que estabelece causas de aumento de pena diversas para o concurso de agente e emprego de arma de fogo. Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento. Dentro deste contexto, importa considerar (i) que a vítima Lucineide se lesionou ao cair da moto no momento da abordagem criminoso, e (ii) o veículo de Henrique foi recuperado destruído, de modo que houve considerável perda patrimonial; além disso, (iii) houve disparo de arma de fogo no crime

praticado contra a vítima Pedro. Dados que incrementam a censurabilidade do comportamento, de sorte que a hipótese é de duplo aumento, tal como levado a efeito na r. sentença." (Apelação Criminal nº 1505281-28.2018.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 03/06/2020).

Neste ponto, cumpre destacar que o crime foi praticado por quatro indivíduos que mantiveram as vítimas presas dentro do carro por cerca de cinco horas, na presença de uma criança de nove anos, e com o emprego de arma de fogo. Desse modo, o problema diz com a proporcionalidade da reação penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa, maior pena.

Assim, majoro a pena em 3/8 pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, perfazendo 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa para o réu Rian, 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa para o réu Rafael e 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 19 dias-multa para o réu Danilo. Na sequência, tendo em vista o emprego de arma de fogo, necessário novo aumento de 2/3, totalizando 09 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa para o réu Rian, 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa para o réu Rafael e 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 31 dias-multa para o réu Danilo.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"E, na hipótese em concreto, não há excesso na dupla cumulação, nos moldes fixados, mas respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização das penas, diante das especificidades colhidas, visto que os réus atuaram em concurso, previamente ajustados e cada qual de forma determinante, para a prática do roubo, enfatizando-se, ainda, terem mantido a vítima privada de sua liberdade por mais de seis horas, sob o jugo de arma de fogo, circunstâncias que, pela maior reprovabilidade das condutas, também respaldam recrudesimento diferenciado, não havendo se falar em adoção do patamar mínimo." (Ap nº 1500078-10.2018.8.26.0544, Des. Rel. Cláudia Fonseca Fanucchi, j. 19.12.19).

No mesmo sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça:

"Dessa forma, na terceira fase da dosimetria, constata-se que está concretamente fundamentado o aumento da pena no índice de 3/8, decorrente do concurso agentes e da restrição de liberdade da vítima por mais de 6 horas, além do agravamento da sanção na fração de 2/3, relativa ao emprego de arma de fogo, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, não havendo falar em excesso de pena." (HC nº 560.059 - SP (2020/0026354-0), Min. Rel. Nefi Cordeiro, j. 26.05.20).

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal. Com efeito, o crime de roubo qualificado denota uma periculosidade acentuada dos agentes, bem como evidente gravidade em concreto, visto que houve restrição de liberdade das vítimas, uma delas criança de nove anos inclusive, além do concurso de quatro agentes armados. Bem por isso, a regra, no caso de roubo qualificado é a fixação do regime inicial fechado em relação à sanção privativa de liberdade (STF, HC nº 74.301-3, rel. Min. Maurício Correa; TACRIM-SP, RJDTACRIM 16/143, 10/119).

Destaca-se ser inviável proceder à detração neste momento, tendo em vista a necessidade da análise de elementos objetivos e subjetivos que somente podem ser aferidos em fase da execução da pena.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RIAN CELSO DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 09 anos e 02 meses de reclusão,

sob regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no unitário mínimo, o acusado RAFAEL FEITOSA FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu DANILO DE MATOS SOUSA, qualificado nos autos, às penas de 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, sob regime inicial fechado, e 31 dias-multa, no unitário mínimo, todos por incursão nos incisos II e V do parágrafo 2º e no inciso I do parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal.

Denego o apelo em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, o celular apreendido ficará disponível para os interessados, desde que comprovada a propriedade, pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, fica determinado seu perdimento, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella -Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Maua, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA